

1520456-77.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/04/2022

... estavam de capacete no momento do roubo.

No mesmo sentido, a testemunha Leandro Luiz Martins, policial civil, ouvida em juízo, narrou que dias antes do reconhecimento fotográfico do réu, em outra ocorrência, conseguiram impedir um roubo em andamento, que estava sendo praticado pelo réu Freddi e outro comparsa.

Nessa tentativa de roubo, os assaltantes utilizaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520456-77.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520456-77.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

FREDDI ALVES BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II; e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta das 16h, na Avenida Diogo de Azevedo, nº 120, Rio Pequeno, nessa cidade e comarca, o acusado, previamente ajustado e com unidade de designios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente à vítima G.M.S..

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, cinco testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. (Fls. 182/183 e 213/218).

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público buscou a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia e ainda a decretação da prisão do acusado, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal afirmando que "é inegável que o acusado será tentado a evadir-se para evitar o cumprimento da reprimenda a ele imposta"

Já a Defesa requereu a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugnou pela fixação da pena base em seu patamar mínimo; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea que deve ser compensada com a agravante da reincidência;

pelo afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo; bem como pela fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de penal e, ainda, do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitativa comprova-se pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico do acusado e da motocicleta Honda CB 250 de cor preta que foi utilizada por um dos autores do roubo, (fls. 11/12), relatório final da autoridade policial (fls. 108), tudo isso aliado à prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

O próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática do crime de roubo na companhia de outra pessoa, nos exatos termos descritos na denúncia e demonstrados pelas filmagens juntadas aos autos. Contudo, alegou que não estava armado com arma de fogo e que ameaçou a vítima com um simulacro.

A confissão do réu, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, foi devidamente corroborada pelas outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Assim é que a vítima G.M.S., ouvida em juízo, após esclarecer as características dos indivíduos que o abordaram e reconhecer o acusado como sendo um dos roubadores, declarou que, na data dos fatos, estava no portão da escola de seu filho, quando duas pessoas o abordaram. Disse que os roubadores estavam em uma moto e o garupa desceu apontando-lhe uma arma de fogo. Afirmou que o réu Freddi foi quem lhe apontou a arma de fogo. Disse que na delegacia fez o reconhecimento fotográfico do réu e não teve dúvidas em identificá-lo, como aquele que desceu da moto e o ameaçou com a arma de fogo.

Também em juízo, ao ser colocado na presença do réu e de outros indivíduos não teve dúvidas em apontar o réu como sendo um dos roubadores já que no momento da ação delituosa o réu estava com a viseira do capacete aberta e pôde ver bem o seu rosto. Informou que a polícia identificou o réu em razão das gravações das câmeras de segurança, da escola de seu filho, nas quais foi possível visualizar as placas de uma das motos utilizadas pelos assaltantes. No mais, informou que no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia lhe foram apresentadas diversas fotos, dentre as quais reconheceu a do réu. Já em juízo, reconheceu o réu em razão da cor da pele e da expressão dos olhos.

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado. Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97).

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEIMALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente.

O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui"(cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Veja-se, ademais, que as declarações da vítima foram confirmadas pelo depoimento em juízo da testemunha André Miguel dos Santos, que trabalha na escola onde ocorreu o

assalto como inspetor de alunos, que informou que na data dos fatos estava na portaria, atendendo um dos pais quando chegaram dois indivíduos em uma moto e efetuaram o assalto. Disse que o garupa que desceu e abordou a vítima estava armado. Não sabe exatamente o que foi subtraído e não saberia descrever características dos assaltantes, pois apenas acompanhou os fatos pela câmera de segurança e os dois assaltantes estavam de capacete. Por fim, informou que os assaltantes abordaram a vítima em apenas uma moto, mas depois, pelas filmagens das câmeras de segurança do colégio, foi possível identificar uma segunda moto utilizada por eles.

No mesmo sentido, a testemunha Ademar Barbosa Santos, ao ser ouvida em juízo, narrou que na data dos fatos estava na portaria da escola quando surgiu uma moto com dois homens e abordaram o pai de um aluno, levando-lhes os pertences. Informou que os assaltantes estavam armados com um revólver. Não sabe o que foi subtraído da vítima. No mais, informou que os dois assaltantes estavam de capacete, com a viseira aberta, mas não pôde ver seus rostos.

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Por fim, a testemunha Natália Guilherme Emed, escrivã de polícia, ao ser ouvida em juízo, informou que não participou do reconhecimento fotográfico do réu pela vítima, apenas das oitivas das testemunhas. Declarou, também, que teve acesso às filmagens das câmeras de segurança do colégio, pelas quais foi possível identificar a dinâmica dos fatos e a placa de uma das motos utilizadas pelos assaltantes. No mais, informou que os assaltantes estavam de capacete no momento do roubo.

No mesmo sentido, a testemunha Leandro Luiz Martins, policial civil, ouvida em juízo, narrou que dias antes do reconhecimento fotográfico do réu, em outra ocorrência, conseguiram impedir um roubo em andamento, que estava sendo praticado pelo réu Freddi e outro comparsa.

Nessa tentativa de roubo, os assaltantes utilizaram uma moto, que posteriormente foi identificada como meio de fuga no roubo da qual foi vítima G.M.S.. Informou que, diante de tal constatação, a vítima foi chamada à Delegacia, onde fez o reconhecimento da moto e do réu. Informou que a motocicleta está registrada no nome do réu. Por fim, informou que foram apresentadas diversas fotografias à vítima quando do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e que não conhecia o réu antes destas investigações.

Já a testemunha Carlos Roberto Monteiro de Oliveira, ao ser ouvida em juízo, declarou que participou da prisão do comparsa do réu Freddi, mas não se recorda dos fatos dos autos. Informou que não estava presente no reconhecimento do réu pela vítima.

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado, ao contrário, o próprio réu confessou a prática do crime e praticamente narrou os fatos de forma idêntica a do policial ouvido como testemunha, fato este que confirma que os depoimentos prestados por policiais apenas por conta de sua atividade, não devem desconsiderados ou sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que tais depoimentos, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de tal depoimento somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes

da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

As causas de aumento de pena impostas na denúncia, também vieram devidamente comprovadas.

Com relação ao concurso de pessoas o próprio réu confirmou que agiu na companhia de outro agente o que foi também relatado pela vítima.

Ora, já se pacificou que para a caracterização do concurso de pessoas não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos. É coautor o agente que, durante a execução do roubo, permanece em companhia de executores *prima facie* mais dinâmicos, ou mais agressivos, ou mais audazes, seja por encorajar os comparsas com sua presença, seja por oferecer-se como soldado de reserva, e, no caso, auxiliando a remoção segura do objeto subtraído e no caso em tela, comprovado nos autos que o réu agiu na companhia do adolescente.

O mesmo, se diga com relação ao uso de arma de fogo e neste ponto, embora o réu tenha dito que estava apenas com um simulacro de arma de fogo, fato é que a vítima e as testemunhas André e Ademar foram uníssonas em afirmar que os roubadores estavam armados e apontaram a arma contra G.M.S.

Ora, diante disso, e ainda considerando que o réu não apresentou o referido simulacro, no momento em que foi preso, não há como olvidar das palavras da vítima e das testemunhas ouvidas, ainda mais porque, já se pacificou que "(...) para a caracterização da causa de aumento de pena que o sujeito ativo porte a arma ostensivamente de modo que ameace a vítima, não sendo imprescindível que venha fazer uso do instrumento para praticar a violência ou grave ameaça".

No mesmo sentido: "A ausência de apreensão da arma, empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SP RJD 10/117).

E ainda: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.

II - Lesividade do instrumento que se encontra *in re ipsa*. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI /Julgamento: 04/11/2008).

Veja-se, portanto, que a versão do réu no sentido de que se tratava de simulacro de arma de fogo restou isolada nos autos.

Caracterizada, portanto, a infração penal, passa-se a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 209/212, já que a pena decorrente dos autos nº 0045162-19.2010.8.26.0050, somente foi extinta em 18/05/2017, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação da pena. Por fim, a condenação definitiva decorrente da prática do delito de roubo majorado julgado perante a 3ª Vara Criminal do Foro de Jundiaí (autos nº 1503194-50.2018.8.26.0309), por fato praticado em 20 de abril de 2018, será aqui utilizado como maus antecedentes, o que permite que a pena base seja aumentada em

1/6, chegando-se ao total de chegando-se a um total de 04 anos e 08 meses; e 11 dias-multa, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Nesse sentido: "Registre-se que, ostentando o réu mais de uma condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste proceder, "bis in idem" (STJ, HC nº 161.653, rel.Min.Sebastião Reis Júnior; HC nº 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC nº 255.259, rel. Min.Maria Thereza de Assis Moura).

Na segunda fase, há que se reconhecer a agravante da reincidência e ainda a atenuante da confissão e assim a pena deve ser mantida no patamar acima fixado, já que se compensam, consoante posição jurisprudencial que vem tomando corpo em nossos Tribunais.

Nesse sentido: STJ: "III - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falem preponderância da primeira". (HC 471.436/PE, j. 11/12/2018).

Não se desconhece posição no sentido de que a confissão do acusado deve ser integral e que tendo o réu negando um dos elementos do tipo penal ela deva ser desconsiderada. Tal posição, contudo, vem sendo rechaçada atualmente por grande maioria da jurisprudência, e se não bastasse isso, considerando ainda que o réu confessou que agiu em conjunto com outra pessoa e ainda que ameaçou a vítima, com um simulacro de arma de fogo, não há como simplesmente desconsiderar seus relatos.

Neste sentido:

Súmula 545 STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. Art. 65, III, d, do Código Penal.

Na terceira fase, em face do concurso de pessoas, a pena deve ser aumentada no mínimo legal de 1/3, chegando -se ao total de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão; e 14 dias-multa.

Considerando ainda o uso da arma de fogo, a reprimenda deve ainda ser majorada em mais 2/3, nos exatos termos legais (art. 157 §2º- A, inciso I, do CP), totalizando 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão; e 23 dias-multa.

Não há que se aplicar a pena de somente uma das causas de aumento, já que o próprio legislador, demonstrou, com a reforma que fez e com as demais que estão sendo feitas, que o crime de roubo merece punição mais severa, sob pena de se afastar da vontade do legislador, ignorando os motivos que o levaram a reputar mais grave o que é, manifestamente, mais grave.

Se não bastasse isso, ressalta-se que para esta magistrada a aplicação do acréscimo mínimo em estrito cumprimento a Súmula da Egrégia Corte Superior, nestes casos estaria privilegiando aqueles que se unem e armados cometem o crime, e, além disso, afronta o princípio da individualização da pena, já que aquele que comete o delito mediante apenas uma causa de aumento seria apenado com a mesma quantidade de pena dos outros.

O aumento mínimo, no caso, empregando-se o mesmo critério de quando se faz presente apenas uma causa de aumento, equivaleria a dar tratamento igual a situações absolutamente desiguais, implicando em apreciação parcial da disposição legal.

Não estamos diante de mera aplicação de critério quantitativo, como sustentam alguns.

Cada causa de aumento descreve circunstância diversa e todas, à evidência, foram eleitas pelo legislador porque evidenciam a maior culpabilidade do autor do crime, ou a maior gravidade do meio empregado para cometê-lo.

Não se trata de somá-las matematicamente, mas sim de reconhecer o incontestável, ou seja, a maior gravidade do crime que é praticado em determinadas circunstâncias expressamente previstas na lei.

Sobre a possibilidade desses dois aumentos, cita-se a brilhante lição do Des. Machado de Andrade: "A regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição") é mera faculdade conferida ao Magistrado, pois a lei é clara ao dizer que pode o juiz

limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação. A gravidade concreta do presente caso está configurada principalmente porque o delito foi praticado pelos réus em concurso de agentes, ameaçando as vítimas com armas de fogo. Já é pacífico o entendimento que a dosimetria entre o mínimo e o máximo da fração de aumento tem por parâmetro o número de causas de aumento. Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a frações de aumento e o fez de forma fundamentada, a exasperação no patamar empregado atendeu ao critério de retribuição penal, em observância aos princípios da razoabilidade, individualização da pena e principalmente da proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a conduta praticada (Apelação Criminal n.º 0001446-58.2018.8.26.0535 6ª Câmara Data do Julgamento 06/02/2020).

Por fim, como não há nos autos provas da condição financeira do réu, o dia multa será fixado no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II; e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-se-lhe a pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão; e 23 dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, seja pela quantidade de pena aplicada ao acusado, sua reincidência e maus antecedentes, ainda, porque é o único que se ajusta e convém ao acusado, pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, pois é inegável a periculosidade e ousadia de quem se põe a praticar assaltos ainda mais na companhia de outro indivíduo e munido de arma de fogo.

Veja-se que o réu sempre que foi solto, se viu novamente na prática de outro crime, o que demonstra que somente o cárcere lhe é suficiente.

Não se pode esquecer que "O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACrim88/87).

Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor. Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ123/547).

Considerando, contudo, que o réu permaneceu solto durante toda instrução criminal poderá apelar desta em liberdade.

Veja-se que apesar do Ministério Público ter afirmado que a prisão do réu nesta oportunidade é necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, porque o acusado "será tentado a evadir-se para evitar o cumprimento da reprimenda a ele imposta", tais ilações, não se justificam já que o réu encontra-se preso, cumprindo pena por outro crime de roubo em regime fechado.

Assim sendo, poderá recorrer desta em liberdade.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada do cálculo aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA